

1501023-89.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Estava em seu segundo dia no tráfico. Não conhecia as testemunhas arroladas, trabalhava em uma lavandaria, com renda de R\$ 1150,00, tendo sido dispensado da data de ontem, tem dois filhos menores de idade e respondeu a atos infracionais equiparados a roubo e tráfico. Antônio Alexandre Barbosa, policial civil que participou da ocorrência, afirmou que se deslocou até o local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Jardim Francisco Morato, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501023-89.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110195/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 17491003 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 1342/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2110195 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

24/01/2022

Aos 24 de janeiro de 2022, às 15 horas, nesta cidade de Francisco Morato, na sala de audiências do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Francisco Morato, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Dra. Renata Marques de Jesus, comigo escrevente abaixo assinado. Presente representante do Ministério Público Dra. Maria Isabel El Maerrawi, foi aberta audiência de instrução e interrogatório (na forma virtual, conforme o art. 17, da Resolução n.º 329/2020 do CNJ, e o item 13, do Comunicado CG 284/2020), nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: o réu WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS, acompanhado por advogado constituído Dr. Edson Soares Ferreira. Presente(s) a(s) testemunha(s) Antonio Alexandre Barbosa e Abel Gonçalves de Souza, a(s) qual(is) foi(ram) ouvida(s). Terminada a(s) inquirição(ões), foi colhido o interrogatório do(s) réu(s). O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) através do Microsoft Teams, arquivado(s) na plataforma One Drive e não será(ão) transcrito(s) em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de

documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito foi dito: Considerando que as partes não postularam novas diligências, declaro encerrada a instrução. Passo a palavra ao representante do Ministério Público para alegações finais, seguido pela Defesa. Pelo Ministério Público foi dito: "MM. Juiz(a), WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 11:30 horas, na Viela Treze, altura do n. 01, Bairro Parque Belém, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, trazia consigo, para fins de comercialização, drogas proscritas no Brasil, nos termos da Portaria n. 344/98 - SVS/MS, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante e, posteriormente, foi beneficiado com liberdade provisória pelo Juízo da Custódia (fls. 83/84). Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 137) e ofertou defesa prévia (fls. 146), no bojo da qual não arguiu nulidades ou questões preliminares. A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 147/148). A instrução processual desenvolveu-se de forma regular com a oitiva das testemunhas arroladas, ao que se seguiu o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução nesta data, tenho que a ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, auto de constatação preliminar de fls. 35/39 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 122/124, em que atestada a natureza e a quantidade das drogas apreendidas em poder do réu. A autoria do crime também é certa e recai sobre o acusado. Segundo apurado, WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS realizava tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Policiais militares em patrulhamento pelas proximidades da linha férrea avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual segurava uma sacola, e decidiram abordá-lo. Com o suspeito, identificado como WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS, no interior da sacola que ele carregava, foram encontradas 150 porções de cocaína e 35 porções de maconha, fracionadas individualmente para venda e acondicionadas em tubos plásticos transparentes, além a quantia de R\$ 163,00 em cédulas de pequeno valor. O denunciado, ao ser questionado pelos policiais, confessou que estava no local comercializando entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, denotam o envolvimento do denunciado com a traficância. O crime foi cometido durante o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, nos termos do Decreto Estadual respectivo. Em Juízo, os policiais civis Abel Gonçalves de Souza e Antônio Alexandre Barbosa, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, confirmaram a dinâmica dos fatos, acima descrita, e seus depoimentos perante a autoridade policial (fls. 10 e 11). Relataram que, em diligências objetivando coibir o crime de tráfico de drogas, deslocaram-se até as imediações da linha férrea, no Parque Belém, local já conhecido como ponto de comercialização de drogas. Em breve observação, avistaram o acusado em atitude suspeita, com uma sacola nas mãos, e decidiram abordá-lo. O suspeito esboçou reação de fuga, mas foi capturado. Na sacola que ele carregava foram encontradas 150 embalagens plásticas contendo cocaína e 35 tubos plásticos contendo maconha, além da quantia de R\$163,00 em cédulas de pequeno valor. Ao ser questionado, prontamente o acusado confessou que ali estava a serviço do tráfico. Diante do contexto, efetuaram sua prisão em flagrante e condução à autoridade policial. Em Juízo, o policial Abel acrescentou, ainda, que o local é de difícil acesso e conhecido pela comercialização de entorpecentes. Observaram o suspeito sentado, com uma sacola nas mãos. Ele tentou fugir, mas por ser uma área de mata densa, não conseguiu ir muito longe e acabou sendo capturado. Ele confessou que estava traficando. As drogas - maconha e cocaína - estavam já fracionadas e guardadas na sacola que viu nas mãos do suspeito, a qual foi deixada no local na tentativa de fuga. Viu, com certeza, a sacola nas mãos do suspeito, que estava sozinho no local. Desde a observação e até a abordagem, não chegou e nem saiu mais ninguém do local. Ele já tinha passagem por tráfico e roubo. No mesmo sentido, o depoimento do policial Antônio Alexandre, que também pontuou que WELLINGTON estava segurando uma sacola no local, que é próximo da linha férrea e já conhecido pelo movimento do comércio ilícito. Na sacola, havia mais de cem

porções de cocaína e algumas porções de maconha, além de dinheiro. Ele admitiu que estava traficando. A comunidade usa a linha férrea para acessar o centro da cidade e a plataforma de embarque. Havia movimento de pessoas, mas com ele, no tráfico, não parecia ter mais ninguém. Perante a d. autoridade policial, WELLINGTON admitiu a conduta ilícita (fls. 12). Disse que estava desempregado e começou a vender drogas, permanecendo na atividade por um mês antes de ser preso. Alegou dificuldades financeiras. Disse que recebia R\$200,00 por dia trabalhado no tráfico. Não soube identificar os responsáveis pela entrega dos entorpecentes ou pelo recolhimento do lucro. Em Juízo, mais uma vez, admitiu que estava vendendo entorpecentes. Disse que passava por uma situação difícil, havia perdido o emprego de motoboy. A despeito de seu depoimento anterior, disse que era apenas seu segundo dia no ponto. Atualmente, está desempregado. Estava trabalhando até ontem. Mora em casa alugada e tem dois filhos menores. Sua companheira está grávida. Nunca respondeu a processo criminal antes. Já respondeu quando menor. Tal é o panorama probatório dos autos, que permite a condenação do acusado. Firmadas, assim, a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime, de rigor a condenação do acusado. Com relação à DOSIMETRIA DA PENA, anoto que o acusado, à época dos fatos, era MENOR de 21 anos. A pena-base há de ser exasperada por força do disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, já que com o réu foi apreendida considerável quantidade de drogas variadas, dentre elas COCAÍNA, de elevada capacidade viciante e nefastas consequências sociais. O réu confessou os fatos a ele imputados. O crime foi cometido durante estado de calamidade pública, na forma do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Trata-se de réu primário. Todavia, a quantidade de entorpecentes apreendida demonstra seu envolvimento com a criminalidade, a afastar a aplicação do redutor previsto no §4.º do artigo 33, da Lei de Tóxicos, circunstância reforçada, ainda, pela anterior apreensão, enquanto menor, pela prática de ato infracional análogo ao crime que é objeto desta ação e ao crime de roubo (fls. 163/197). O regime inicial de cumprimento da pena, de qualquer modo, deverá ser o fechado, em razão da natureza hedionda do crime, ficando vedada a substituição da pena privativa de liberdade. Ante o exposto, pugno pela condenação do acusado nos termos da denúncia, observando-se os critérios acima para fixação da pena". Pela Defesa foram apresentadas alegações finais orais. As alegações finais foram gravadas através do Microsoft Teams, arquivadas na plataforma One Drive e não serão transcritos em papel (Provimento 8/2011 da Egrégia Corregedoria da Justiça), permitindo aos procuradores o acesso a qualquer tempo, que constitui, nos termos do art. 405, § 1º e 2º do CPP, meio idôneo de documentação e se destina a obter maior fidelidade das informações. Em seguida foi proferida a sentença pelo(a) MM.(a) Juiz(a) de Direito: "Vistos. WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, 'j', do Código Penal, porque no dia 22 de abril de 2021, por volta das 11h30, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, trazia consigo, para fins de comercialização, drogas proscritas no Brasil, nos termos da Portaria nº 344/98 -SVS/MS, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 5/7). Em audiência de custódia foi concedido o benefício da liberdade provisória ao réu (fls. 83/84). Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 146) e a denúncia foi recebida (fls. 147/148). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado. Mídia arquivada. Em debates o Ministério Público pugnou

pela procedência do pedido, observando a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com início de cumprimento de pena no regime fechado. A Defesa, por sua vez, requereu observância do redutor em seu máximo legal, com fixação de pena mínima, a ser substituída por restritiva de direitos. É o relatório. Fundamento e decido. À luz das provas carreadas aos autos, a pretensão inicial merece prosperar. A materialidade restou comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 8/12), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação provisória (fls. 59/63), além do exame químico-toxicológico de fls. 122/124, que constatou as presenças de tetrahydrocannabinol (THC) e de cocaína nas amostras

analisadas. A autoria também é certa, corroborada pela própria confissão. Na fase extrajudicial o réu confessou a prática do delito, narrando que vendia entorpecentes e ganhava duzentos reais por dia (fls. 12). Em juízo, mantendo sua versão anterior, declarou ter 21 anos de idade. Estava em situação difícil, tem filho e sua moto quebrou. Estava em seu segundo dia no tráfico. Não conhecia as testemunhas arroladas, trabalhava em uma lavandaria, com renda de R\$ 1150,00, tendo sido dispensado da data de ontem, tem dois filhos menores de idade e respondeu a atos infracionais equiparados a roubo e tráfico. Antônio Alexandre Barbosa, policial civil que participou da ocorrência, afirmou que se deslocou até o local com vista ao tráfico, já que é conhecido da unidade como ponto de venda de drogas. É de difícil acesso e foram a pé. Identificaram o réu, segurando uma sacola. Na hora da abordagem, ao se identificarem, ele tentou se evadir, mas foi detido. Ele tinha uma sacola com cerca de 150 papérolas de cocaína, R\$ 163,00 em dinheiro e 35 porções de maconha, tudo pronto para venda. Em conversa informal ele confessou a traficância. Não conhecia o réu antes dos fatos. A comunidade usa o local (linha férrea) para chegar ao Centro da cidade, mas não reparou se alguém estava com o réu. Na mesma esteira o depoimento do também policial civil Abel Gonçalves de Souza, relatando que o local é conhecido por tráfico de drogas. É de difícil acesso. Adentraram ao trilho, na região de mata, e ao chegar no local o réu estava sentado em um barranco com uma sacola em mãos. Ele viu os policiais, largou a sacola e correu. Foi alcançado e se rendeu. Ele confessou que estava a serviço do tráfico e tinha passagem por roubo e tráfico. Na sacola dispensada havia dinheiro e drogas, maconha e cocaína, sem se recordar a quantidade. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Os entorpecentes estavam em porções fracionadas para venda. Ninguém passou no local. Ele estava sozinho. É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que o acusado e os policiais militares não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente. Ademais, a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade: “É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011); “O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586); “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189); “Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275); “Os policiais não são

proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" (TJMG, RT 604/407). A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório. E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que os policiais civis teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar a lisura do trabalho policial. Nesse sentido: "PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câmara - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78). A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos dos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos. Dentro desse quadro, os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, repita-se, foram harmônicos e convergentes, corroborando a própria confissão, levando à certeza da autoria. Sendo assim, a variedade, a quantidade e nocividade das drogas apreendidas, a forma como embaladas, o fato de o local da apreensão ser conhecido dos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, bem como o depoimento seguro prestado pelas testemunhas, corroborado pela própria confissão, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião. Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que as simples condutas do réu, consistentes em "trazer consigo" as substâncias entorpecentes, já são suficientes para caracterização do delito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco). No mesmo sentido: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável à prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542); "Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des.

Fernando Torres Garcia). Ressalta-se que a quantidade e variedade de entorpecente, além da forma como se deu sua apreensão demonstram a traficância e não autorizam eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06): "DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade -

Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09). E o fato de o acusado eventualmente afirmar que é usuário de droga, o que não se vislumbra, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor. Vale destacar, ainda, que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante: "(...) a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra." (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498); "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (TJSP; 9.ª Câmara Criminal, Ap. n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, j. em 31.03.2016); "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104). Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de não desprezível quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio. Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, amoldando-se a conduta praticada pelo réu à figura típica prevista no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena: Sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal e em observância ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que autoriza que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria a natureza do entorpecente, a quantidade, a personalidade e a conduta social do agente, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal (v.g. STF, HC nº 96.655, rel. Min. Cármen Lucia; STF, HC nº 107.784, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC nº 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 235.524, rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC nº 223.447, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC nº 179.086, rel. Min. Gilson Dipp). No mesmo sentido: "REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda de piso acima do mínimo legal, em razão da natureza e a excessiva quantidade do estupefaciente apreendido, encontra-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. [...] 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017). O réu é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 44/45), contudo, na hipótese, foi localizado com cocaína, entorpecentes de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda, pois seria desarrazoado punir aquele que vende "maconha" na mesma medida daquele que vende entorpecente altamente viciante, que além de causar um impacto muito maior na saúde do usuário, ainda repercute na sociedade e na família, somado ao fato de corroborar com a prática delitativa daqueles que não possuem condições financeiras de sustentar o vício. Segundo o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, "A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na

individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 378). No mesmo sentido, defende Ricardo Brasileiro de Lima que "Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (in Legislação criminal especial comentada, 2ª edição, JusPODIVM, 2014, p. 787). Registre-se que a cocaína é considerada um dos entorpecentes mais nefastos e viciantes, o que traz maiores danos à saúde pública, sendo de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por ser proporcional à quantidade e natureza. Assim, ponderando tal circunstância (natureza), fixo a pena-base com o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à fração a ser aumentada, vale destacar não haver previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). Prosseguindo, nos termos do artigo 68, do Código Penal, verifico presentes as circunstâncias atenuantes da confissão (artigo 65, III, "d", do Código Penal) e da menoridade (artigo 65, I, do Código Penal, fls. 145), razão pela qual retorno a reprimenda imposta ao seu mínimo, sendo nesta fase vedada a fixação abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ). Deve, no entanto, ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), quando já estava decretado o estado de calamidade pública, com recomendação do isolamento social e outras medidas públicas (Decreto Estadual nº 64.879/20 e Decreto Legislativo nº 6/2020), o que reduz a vigilância. A prática de crime em cenário no qual toda a população passa por privações e incertezas e em meio a diversas recomendações de recolhimento domiciliar e restrição de atividades de toda ordem é ainda mais reprovável e merece resposta penal diferenciada. A situação atualmente vivida é excepcional e, sem dúvida, do conhecimento de todos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. APELO MINISTERIAL. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL, E DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, valoradas como negativas as circunstâncias relacionadas à natureza da droga (cocaína, acondicionada na forma de tijolos) e do seu transporte entre cidades. Na segunda etapa, pedido ministerial acolhido, para reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP). Prática do crime durante a pandemia de COVID-19. Lei não prevê nenhuma condicionante finalística ou modal para que a agravante incida. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as penas ainda foram reduzidas em 1/10, dada a preponderância da atenuante (art. 67, CP). A quantidade dos entorpecentes apreendidos (quase dois quilogramas de cocaína) e seu alto valor no comércio clandestino de entorpecentes demonstram envolvimento do apelado em atividades criminosas, impedindo, portanto, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o qual fica afastado. Penas redimensionadas para 5 anos e 3 meses de reclusão e 524 dias-multa. REGIME PRISIONAL. Imposição do regime inicial fechado, ante a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal), a par da gravidade concreta do delito praticado. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabível a concessão de sursis ou de

substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena concretizada, Recurso ministerial provido para, afastado o privilégio e reconhecida a agravante do art. 61, II, "j", do CP, redimensionar as penas do apelado, bem como fixar-lhe o regime inicial fechado." (TJSP; Apelação Criminal 1522780-54.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) – grifos nossos. No presente caso, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois se trata de uma benesse que deve ser aplicada em casos pontuais em que há pequeno potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado, o que, obviamente, não é o caso do réu. O referido § 4º prevê que o benefício será aplicado ao agente que, além de ser primário e portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça que a dedicação à atividade criminosa é óbice à aplicação da causa de redução de pena, independentemente do grau de comprometimento do agente com o crime, ou da complexidade da estrutura da organização criminosa (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.357.182/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). Assim sendo, os elementos apurados, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução, especialmente considerando a existência de aplicação de medidas socioeducativas anteriores aos fatos por ato infracional equiparado ao delito de roubo (fls. 45 e 163/164) e representação por equiparação ao crime de tráfico (fls. 185/197), idêntico ao tratado nestes autos, estando o réu, ainda, em descumprimento de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade (fls. 180/184), aliando-se à expressiva quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, perfazendo um total de 35 porções de maconha e 150 porções de cocaína (fls. 16), tendo como destinação certa a venda, tem-se que não se trata de traficante eventual ou de mera participação para sustento do próprio vício. Todas as provas e circunstâncias concretas demonstram que o acusado faz do tráfico seu meio de vida, mostrando-se incabível a aplicação do § 4º do artigo 33, da Lei De Drogas: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal. 2. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. A Corte local deixou de aplicar a minorante respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, que demonstraram que o paciente dedicava-se à atividade criminosa, excluindo a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 4. A ausência de comprovação de atividade lícita não pode, por si só, levar à conclusão imediata de dedicação à atividade ilícita. Todavia, o conjunto de circunstâncias consideradas pelo Tribunal de origem, de fato, sinaliza essa dedicação, sobretudo, por ser o paciente conhecido no meio policial devido a seu envolvimento no tráfico de entorpecentes, não se olvidando, ainda, da considerável quantidade de droga apreendida. 5. Desconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demanda ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 421.925/SP, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso. "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgInt no HC 467.947/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe de 01/02/2019) - grifos nossos. "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto a consideração de atos infracionais anteriores na dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência. Entretanto, este Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo inclusive, fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. III - Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. IV - Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) - grifos nossos. "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRAFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL COMETIDO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do recorrente ter praticado ato infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a atividades criminosas. Precedentes da Quinta Turma. 2. Entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial a teor do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RESp 1653501/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 09/05/2017, data da Publicação DJe 17/05/2017) - grifos nossos. "HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza " e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada." (STJ, Quinta turma, HC 121509/SP, relator Ministro FELIX FISHER, data do julgamento 18/02/2010 e data da publicação DJe 29/3/2010). "HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. MODO INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante por entender que a quantidade dos entorpecentes apreendidos (219,8 gramas de maconha e 1,6g de cocaína) e o registro de atos infracionais na adolescência, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes, comprovam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Esta tem Corte decidido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. 5. Mantido o quantum da pena do paciente em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, 'b', e 44, I, ambos do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 537.485/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019. Esta pena torna-se definitiva, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento e de diminuição. O valor do dia-multa deve ser calculado nos termos do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, sendo fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do pagamento, tendo em vista a situação econômica do acusado. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, c.c. art. 42, da Lei nº 11.343/2006, estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão e considerando a quantidade total líquida de entorpecente apreendido e o envolvimento infracional recente justificam o afastamento da substituição da pena e a imposição de regime prisional semiaberto. Precedentes: "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "c", parte final, do RISTJ, e na Súmula 568/STJ, conheço do agravo para dar provimento parcial a o recurso especial, para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2/3, redimensionando a pena da agravante para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 227 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantidos os demais termos da condenação." (STJ - Agravo em Recurso Especial nº 1743264-SP (2020/0208712-9), Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em: 25/09/2020. - grifos nossos. Ressalta-se que, no presente caso, o redutor não foi concedido, tampouco foi fixado regime inicial fechado pela presente decisão, de modo que não há desrespeito ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603-SP (item 4), o qual determina a não imposição de regime inicial fechado aos condenados por prática do crime de tráfico privilegiado. Ainda que assim não fosse, impossível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante do montante da pena, da reincidência e também da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, somando um total líquido aproximado de 246g, o que justifica a não substituição da reprimenda (STJ, Quinta Turma, HC 24914/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 14/04/2013); "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 11,2G DE COCAÍNA, 179,1G DE MACONHA E 554ML DE LANÇA-PERFUME - PENAS - AFASTAMENTO DA

AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "j" - IMPOSSIBILIDADE - O NECESSÁRIO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS GARANTIU, POR INFELIZ VIA TRANSVERSA, O ANONIMATO E A IMPUNIDADE DE USUÁRIOS E TRAFICANTES - AGRAVANTE MANTIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A INDICAR QUE O ACUSADO, CONQUANTO PRIMÁRIO, FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA - REGIME FECHADO ADEQUADO - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA - IMPROVIMENTO DO RECURSO" (TJSP; Apelação Criminal 1514354-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020) - grifos nossos. Ademais, tais benefícios são incompatíveis com a finalidade da Lei nº 8.072/90, que dá tratamento mais rigoroso aos chamados crimes hediondos e assemelhados. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar WELLINGTON DOUGLAS DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, 'j', do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. O réu poderá recorrer em liberdade, até porque assim respondeu ao processo, não havendo, ainda, razões para que seja decretada a sua prisão cautelar: "I. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, o seu direito de apelar nesta condição somente lhe pode ser denegado se evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quando da prolação da sentença (Precedentes). II. Inexiste motivação convincente se não foi indicado qualquer fato novo que justifique a expedição de mandado de prisão (Precedentes). (...) Writ concedido." (STJ, 5ª Turma, HC nº 51609/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 04/05/06, DJ 19/06/06, p. 161); "1. A necessidade de recolhimento dos réus à prisão pra recorrer deve estar devidamente motivada, sendo insuficiente a mera consideração acerca do caráter hediondo ou da gravidade do delito. Precedentes do STJ e do STF. 2. Ordem concedida para garantir aos pacientes o direito de apelar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura se por outro motivo não estiverem presos." (STJ, 5ª Turma, HC nº 46035/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/05, DJ 10/04/06, p. 243). Autorizo a incineração das drogas, nos termos dos artigos 50, §§ 3º e 4º e 72, ambos da Lei de Tráfico, destruindo-se amostras guardadas para contraprova. Comunique-se nos termos dos art. 524-A, § 2º, e 525, das NSCGJ. Nos termos dos artigos 63, I e § 1º, e 64, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 16), pois decorrente da prática do crime em questão. Oficie-se, após comprovação pela autoridade policial do depósito do referido valor nos autos, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais: "o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gon-çalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." - grifos nossos (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib). Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias." Pelo Ministério Público foi dito não ter interesse em recorrer. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado para o Ministério Público. A Defesa manifestou interesse em recorrer da sentença. Assim, recebo o Recurso

interposto, devendo a i. Defesa apresentar as razões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Geziel Gomes Barbosa, Escrevente Téc. Judiciário, subscrevi.

MM. Juiz(a) de Direito:

Promotoria de Justiça:

Réu:

Defesa:

Certifico e dou fé que o presente termo foi lido e achado conforme pelas partes presentes e por seus procuradores, os quais saem intimados de seu inteiro termo nada tendo a opor quanto ao seu conteúdo. Certifico ainda que, havendo sido presente o termo